

1504636-61.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... mesmo surpreendidos em plena atividade de tráfico, para a qual vinham previamente preparados em situação clara de associação, inclusive dispondo para tanto de aparelhos celulares, instalação elétrica puxada para o ponto de tráfico para o carregamento dos aparelhos, rádio comunicador e arma de fogo municiada e apta ao disparo, demonstrada a permanência da sociedade que em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1504636-61.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504636-61.2022.8.26.0228 - 2022/000273

Autora:

Justiça Pública

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

DANIEL TEODORO DA SILVA JUNIOR e LUCAS SANTOS DA ANUNCIAÇÃO BATISTA

Juíza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófar

Vistos.

DANIEL TEODORO DA SILVA JUNIOR e LUCAS SANTOS DA ANUNCIAÇÃO BATISTA, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas dos artigos 33, caput, e 35, em combinação com o artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 e com o artigo 61, inciso II, alínea j, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, em data e local incertos, ter-se-iam associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes dos artigos 33, caput, e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/06, com emprego de arma de fogo; bem como porque teriam, no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta de 22h, na Rua Algard nº 15, Capão Redondo, nesta cidade e Comarca, durante estado de calamidade pública decretado em decorrência da pandemia do covid-19, transportado e trazido consigo, para entrega a consumo de terceiros, com emprego de arma de fogo, 700 gramas de maconha, 200 gramas de cocaína e crack e 320 mililitros de lança-perfume, substâncias determinantes de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram presos em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 69/72).

Os acusados foram regularmente citados e notificados (fls. 98 e 101), e

apresentaram defesa preliminar por meio da Defensoria Pública (fls. 111), recebida a denúncia (fls. 112) e renovada a citação.

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de duas testemunhas, tendo sido os réus interrogados.

Manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação dos acusados, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, ou a fixação de penas no mínimo, atenuadas por confissão e com máxima redução para Daniel, em regime brando tomada detração, com substituição, sendo facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares de ambos os delitos, que se configuraram consumados, clara a tipicidade, não havendo dúvidas quanto à autoria, correta a classificação dada às condutas, atuando a causa de aumento posta na denúncia, bem comprovada.

O réu Daniel, em solo policial, disse que estava na porta de sua casa na companhia de Lucas, quando foi abordado por policiais militares; há uma "biqueira" no local, os policiais capturaram o traficante, mas quando perceberam que era menor de idade, soltaram-no e detiveram os réus; não portava entorpecentes para venda, tinha só um cigarro de maconha para uso próprio e seu aparelho celular; a arma de fogo localizada pelos policiais estava na posse do menor; conhece o menor pelo prenome Richard, moravam na mesma rua, mas não soube informar o numeral da residência (fls. 23).

Ouvido em Juízo, Daniel admitiu a prática dos delitos; estava na viela atrás do portão, fazendo a "troca de plantão" com o menor Richard, traficando; Lucas e mais dois rapazes estavam na fila para comprar drogas; estava contando as drogas abaixado no chão, Richard estava com um revólver na mão; chegaram policiais, abordaram todos; os dois clientes que eram menores foram liberados; Richard ficou no local, um policiais levou-o de lado e perguntou se ele tinha informações, ele levou os policiais a uma "casa bomba" na viela de baixo, de onde os policiais trouxeram uma mochila, um caderno e rádio comunicadores; em sua posse foram apreendidas porções de maconha, haxixe, cocaína, crack, lança e K2 e R\$ 280,00 que Richard tinha lhe passado; Lucas só tinha 10 reais, ficou porque tinha passagens, até então não o conhecia; morava na favela em questão, na mesma viela, com sua mulher e seu filho de 2 anos; havia uma semana que estava trabalhando no tráfico, porque estava desempregado; é usuário eventual de maconha; não deu declarações na delegacia, só forneceu material gráfico; não conhecia os policiais anteriormente; negou antecedentes (22 anos).

O réu Lucas, em solo policial, disse que foi à viela, local de venda de drogas, para fumar maconha na companhia de Daniel, ocasião em que policiais militares os abordaram; os policiais capturaram um adolescente, com o qual localizaram um pacote de drogas e um revólver e que indicou um imóvel onde estariam acondicionados mais entorpecentes; os policiais liberaram o adolescente, o qual não conhecia; negou que estivesse portando entorpecentes para traficar ou dinheiro, trazia consigo apenas seu telefone celular (22).

Ouvido em Juízo, Lucas negou a prática dos delitos; saiu de casa para ir comprar uma porção de maconha na "biqueira" do portão; o traficante que estava lá falou para esperar que ia "virar o plantão", ficou esperando, chegaram mais dois clientes, nisso chegou um policial que os abordou, pelo lado de dentro do portão policiais abordaram Daniel e outro rapaz; já tinha pego droga com Daniel, mas não tinha vínculo com ele, não conhecia o outro rapaz; tinha consigo somente R\$ 20,00, não tinha consigo drogas nem celular, o policial lhe disse que já estava preso por tráfico, porte e corrupção de menores, exigindo que "trocasse um favor" para não ser preso; Daniel estava dentro do portão com as drogas; os outros abordados eram menores e foram dispensado; o menor que foi pego com Daniel entregou a casa que tinha dentro da viela, de onde os policiais trouxeram uma bolsa com drogas, celulares e um rádio; até então não sabia quanto a essa casa; não conhecia os policiais anteriormente; mora no Jardim Don José, mas foi comprar drogas no local

porque em seu bairro não tenha e gosta da droga que vende ali; tinha pedido o dinheiro emprestado para sua mãe, trabalhava fazendo entregas a pé e de bicicleta para aplicativos; é usuário eventual de maconha, cocaína e lança-perfume; não conhecia os policiais anteriormente; teve condenação anterior por tráfico, foi preso com drogas na mesma rua e respondeu por porte de drogas (23).

A negativa apresentada pelos acusados, carente em si de verossimilhança, vem isolada nos autos, confrontada pelo mais da prova colhida, a qual demonstra à sociedade a realidade da hipótese acusatória.

As circunstâncias da prisão dos réus e da apreensão das várias porções de drogas, do dinheiro, celulares e ainda o rádio HT foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então os acusados, apresentaram relatos detalhados e convincentes, coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

O policial militar Marco relatou em Juízo que estavam em uma operação e fizeram incursão no interior da comunidade; viram os dois réus parados em um beco, eles se mostraram nervosos quando viram os policiais, de modo que foram abordados; Daniel levava na cintura um revólver de calibre 32 municiado com cinco munições, uma delas picotada, não se recordava se com ou sem numeração, e uma mochila nas costas dentro da qual havia porções de cocaína, crack e maconha e um caderno com anotações sobre o tráfico; não havia dinheiro com Daniel; Lucas tinha com ele uma bolsa menor vermelha onde havia porções das mesmas drogas com as mesmas embalagens e também a quantia de 280 reais; do lado dos réus havia um banco de madeira onde estavam três aparelhos celulares e um rádio HT, havia um fio de energia puxado de uma casa que era usado para o carregamento dos aparelhos; os réus admitiram que traficavam e disseram que o revólver era para fazer a segurança "da biqueira" e que os telefones celulares e o rádio HT eram para serem informados da presença da polícia no local; os réus não mencionaram se eram moradores da comunidade, nenhum mencionou que estivesse em frente de sua casa; não foi abordado nenhum adolescente; não havia mais ninguém no local no momento da abordagem.

O policial militar Marcelo descreveu em Juízo que estavam em operação, fizeram incursão na comunidade, local conhecido por conta de várias denúncias de tráfico; os dois réus estavam dentro de uma viela, um ao lado do outro, próximo deles havia três celulares e um rádio HT; com Daniel, na cintura, encontraram um revólver Taurus de calibre 32, com munições, inclusive uma picotada, com numeração raspada; e uma mochila nas costas com drogas, porções de maconha, cocaína, haxixe, drogas variadas, não se recordava se havia dinheiro; com Lucas havia uma pochetezinha que continha as mesmas drogas com mesmas embalagens, como também dinheiro; os réus falaram que a arma era para a segurança, que os HTs e os celulares eram para se conversarem entre si e acerca da presença da polícia; entraram na comunidade por local incomum, de modo que não foram percebidos pelos réus, os réus não mencionaram se eram moradores da comunidade; não havia mais ninguém no local no momento da abordagem.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

A ausência de outras pessoas além dos próprios réus envolvidas na ocorrência foi informada pelas testemunhas, aí porque não houve possibilidade de serem conduzidas perante a autoridade policial outras testemunhas, não sendo esperado que os policiais saíssem a cata de compelir terceiros não participantes do fato a acompanhá-los para dar conta de coisa que não presenciaram.

Restou pois bem assentado que os réus foram mesmo surpreendidos em plena atividade de tráfico, para a qual vinham previamente preparados em situação clara de associação, inclusive dispondo para tanto de aparelhos celulares, instalação elétrica puxada para o ponto de tráfico para o carregamento dos aparelhos, rádio comunicador e arma de fogo municiada e apta ao disparo, demonstrada a permanência da sociedade que em muito supera de comparsaria eventual.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pelos relatos coincidentes das testemunhas, de tal sorte que materialidade e autoria dos delitos encontram-se perfeitamente comprovadas.

As drogas vêm descritas no auto de apreensão de fls. 21, estando a materialidade do delito demonstrada pelo auto de constatação de fls. 41/45 e pelo laudo químico toxicológico de fls. 107/110, em que apontada a presença dos princípios ativos característicos nas substâncias apreendidas.

A quantidade (1.078 porções), a variedade (maconha, cocaína, crack e lança-perfume), o modo de disposição das drogas (repartidas entre os dois réus) e as circunstâncias em que apreendidas, quando postados os réus em ponto estabelecido de tráfico, inclusive dotado de ponto de energia, aparelhos de comunicação e arma de fogo, não se mostram compatíveis com destinação outra que não o comércio ilícito, para o qual evidentemente associados os acusados.

A arma apreendida foi examinada, vendo-se que, a par de ter sido apanhada com o réu municiada, era apta ao disparo, inclusive com os cartuchos apreendidos (vide o laudo de fls. 126 a 131), bem caracterizada a causa de aumento de pena.

A condenação dos acusados é, pois, de rigor. Passo à dosagem das penas que lhe serão impostas.

Aos delitos descritos pelo caput do artigo 33 e do artigo 35 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, as quais, consideradas exclusivamente para fixação da base, não se mostram de todo desfavoráveis aos acusados, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico e de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação. Atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em observância ao princípio da legalidade (Súmula STJ 231).

Embora o réu Lucas seja reincidente, como comprova a certidão de fls. 46/48, uma vez que tal circunstância atuará adiante, entre outras, para obstar a diminuição da pena na forma do parágrafo 4º ao artigo 33, consistindo em elementar, não se presta a caracterizar a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, desde que assim não fosse ocorreria bis in idem.

Não atua, ademais, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, apontada na denúncia, reformulado, nesse ponto, o entendimento desde Juízo.

Com efeito, muito embora o crime realmente tenha sido praticado quando em vigor situação de calamidade assim reconhecida pelo poder público, decorrente da pandemia da doença provocada pelo corona vírus, não se observa que essa circunstância tenha sido algo relevante na prática do delito ou mesmo que da conduta tenha resultado algum efeito sobre a situação calamitosa.

Tratando-se, no caso, de circunstância meramente accidental, que não propiciou facilidade para a prática criminosa e nem tampouco foi impactada pela conduta do réu, não justifica o agravamento da punição.

Nesse sentido:

Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apreensão de maconha - Insurgência do réu - Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei nº

11.343/2006 - Não cabimento - Circunstâncias da prisão e quantidade de entorpecentes apreendidos que afastam tal pretensão - Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Dosimetria. Primeira fase - Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da quantidade de entorpecente apreendido (quase 1 kg de maconha), na fração de 1/6 (05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa). Segunda fase - Atenuante de confissão espontânea compensada com a agravante de reincidência - Ainda na segunda fase, incidiu a agravante de calamidade pública em razão do Covid19, na fração de 1/6 - Respeitado o entendimento do nobre julgador, a agravante contida no art. 61, II, alínea "j", CP, não tem aplicação no caso - Inexistência de relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública (Coronavírus) e a prática do tráfico de drogas - A exasperação da pena é devida quando o agente se aproveita de uma situação, para o cometimento do crime, o que não ocorre na espécie - Agravante afastada. Terceira fase - Redutor que não incidiu na espécie - Réu

reincidente - Regime fechado que fica mantido - Recurso provido em parte para afastar a agravante de calamidade pública, redimensionando-se, assim, o quantum da reprimenda. Mantida, no mais, a r. sentença. (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, Apelação Criminal 1516263-33.2020.8.26.0228, deram parcial provimento, V.U., j. 25/3/2021).

No mesmo sentido: TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Andrade Sampaio, Apelação Criminal 1512777-40.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021; TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Andrade Sampaio, Apelação Criminal 15'6422-

73.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021; e TJSP, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Francisco Bruno, Apelação Criminal 1517341-62.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021.

Não incide a causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º ao artigo 33, concebida para adequação da pena a conduta apenas eventual e de pequeno vulto, não sendo esse o caso dos autos.

Além de ser Lucas reincidente, os réus levavam, repartido entre ambos, mais de mil porções de drogas variadas, prontas para venda, em local apontado como ponto de tráfico de intenso movimento, evidenciada pelas circunstâncias do evento atuação em tráfico organizado e dedicação à atividade ilícita, conduta incompatível com a benesse legal.

Não bastasse isso, não fizeram os réus prova adequada de dedicação a ocupação lícita e de desenvolvimento de vida regrada e ordeira, ausente comprovação, que lhe cabia, de bons antecedentes (cuja presença não decorre apenas da ausência de maus antecedentes e demanda prova positiva a cargo da defesa).

Atua sobre as penas de ambos os delitos a causa especial de aumento de pena prevista pelo artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, dado o emprego de arma de fogo tanto para o tráfico quanto para a associação mais amplamente estabelecida para a prática de outras condutas de tráfico, pelo que vão as penas, com aumento de um sexto, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Verificado o concurso material entre os crimes, aplicam-se cumulativamente as penas de ambos, que totalizam 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime fechado, único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, tanto em vista do quantum fixado, quanto atendida a gravidade objetiva das condutas em exame, que reclamam reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câm. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Ausentes os requisitos legais, inviável substituição da pena corporal.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar os réus DANIEL TEODORO DA SILVA JÚNIOR, qualificado as fls. 28, e LUCAS SANTOS DA ANUNCIAÇÃO BATISTA, qualificado as fls. 27, por infração aos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos em combinação com o artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar dos acusados no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena, é patente o risco de que soltos procurem obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhes facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Autorizo que se proceda à destruição das drogas e da arma apreendidas. Oficie-se desde logo para tanto.

Após o trânsito em julgado a) elabore-se cálculo de multa e intimem-se os réus para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeçam-se e encaminhem-se cartas de guia / aditamentos; c) proceda-se ao leilão dos aparelhos celulares e rádio apreendidos a fls. 21 com transferência do produto arrecadado ao Funad, decretado seu perdimento em favor da União, desde que empregados para a prática dos crimes; d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei, deferida aos réus a gratuidade.

Publicada pela liberação nos autos digitais na data abaixo indicada; intimem-se; comunique-se.

São Paulo, 5 de novembro de 2022.

VAI ESTE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME É APONTADO EM SUA MARGEM SUPERIOR / DIREITA